

1504311-23.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... no que diz respeito aos crimes de homicídio e furto, nos quais já se pacificou que a simples posição topográfica dos parágrafos em nada impediria a figura do crime "qualificado- privilegiado", ou mesmo o reconhecimento da figura do "repouso noturno" aos delitos de furtos qualificados.

A doutrina então começou a analisar tais decisões e passou-se a considerar nestes casos que "a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504311-23.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504311-23.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JENNIFER NATALIA DE SOUSA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

JENNIFER NATALIA DE SOUSA, HERBERT WENDELL SANTOS RODRIGUES e BIANCA BARBOSA GASTALDO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como, no artigo 244-B, da Lei nº 8069/90, ambos c.c artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 21h42, na Avenida Presidente Castelo Branco, 6061, Barra Funda, nesta cidade e comarca da Capital/SP, agindo previamente ajustados e com unidade de designios com a adolescente W. C. do N. S., subtraíram para si diversos itens e materiais de construção, avaliados em R\$ 8.649,93, pertencentes à empresa vítima Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolage, representada por Augusto Cesar Ferreira da Silva.

Ainda, consta na denúncia que JENNIFER NATALIA DE SOUSA, HERBERT WENDELL SANTOS

RODRIGUES e BIANCA BARBOSA GASTALDO, corromperam a adolescente W. C. do N. S. , ao praticarem com ela o furto supramencionado.

A denúncia foi recebida (fls.151), os réus foram citados e notificados (fls.169/174) e apresentaram Resposta à Acusação (fls.177/178). Por provocação da Defesa (fls. 177/178) e, após manifestação do Ministério Público (fls. 182) os autos foram remetidos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do artigo 28-A do CPP que se manifestou a fls. 192/202 quanto à impossibilidade de oferta de ANPP em relação à acusada JENNIFER e determinando, mediante confissão, a apreciação da possibilidade de oferta de ANPP em relação aos acusados HERBERT e BIANCA.

Mantido o recebimento da denúncia (fls.208/210), e não sendo o caso de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual, decretada a revelia dos acusados, e frustrada, portanto, a possibilidade de ANPP, foram ouvidos o representante da vítima e as testemunhas. Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com a condenação dos acusados como incurso nos artigos 155, §4º, inciso IV, cc artigo 14, inciso II do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90, cc artigo 61, II, j e 70 do Código Penal.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação à acusada JENNIFER (artigo 65, inciso I, CP), o afastamento da agravante referente à calamidade pública, o afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, o reconhecimento da tentativa a diminuição na fração máxima, fixação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls.01/03), Termos de Depoimento e de Declarações (fls.04/05 e 06/07), Boletim de Ocorrência (fls.11/16), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls.17/28), Relatório Final (fls. 115/117) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Ouvido em juízo, Augusto Cesar Ferreira da Silva, representante da vítima, esclareceu que trabalha na loja da Leroy Merlin e que no dia dos fatos estava de plantão. Uma funcionária do caixa informou sobre a passagem de uma moça, entre os caixas, com uma sacola preta pesada. Encontrou a moça no estacionamento da loja. Perguntou se tinha mais gente com ela. Ela disse que não. Em seguida, verificaram pelas câmeras de vídeo que ela havia sido deixada na loja por um veículo peugeot azul e foi possível ver o motorista, a quem reconheceu na delegacia como a pessoa abordada pela polícia no veículo peugeot. Avisaram a polícia militar que logrou localizar o veículo. Salvo engano, os bens que foram encontrados no veículo não eram da Leroy Merlin. Pelas imagens, quando a moça entrou na loja ela entrou com mais uma mulher, embora tivesse dito que estava sozinha. Do que foi possível ver nas imagens, aparentava que a outra mulher escolhia o que iam pegar e mocinha só ia colocando os bens na sacola. A adolescente já foi pega em outras lojas da Leroy Merlin. Sabe porque a imagem dela já foi difundida em um grupo de whatsapp da empresa.

Ouvida a policial militar Andressa Meireles Pereira esclareceu que foram acionados via COPOM e quando chegaram no local a menor estava detida pelo pessoal da segurança. Ela falou que entrou com uma moça para pegar uns produtos. Os comparsas estavam esperando do lado de fora. Ela falou da marca do carro que ela indicou. No estacionamento não encontraram o veículo. Na Marginal, próximo da quadra da Águias de Ouro avistaram o peugeot que ela referiu. Abordaram os indivíduos e no carro encontraram os produtos. Eles desconversaram. Tinha dois rapazes, uma mulher e uma criança. Uma das moças contou a verdade: disse que entrou na loja jogou os pertences dentro da bolsa na loja uma conseguiu sair a outra não. A adolescente

disse que tinha um carro esperando.

Ouvido o policial militar Paulo César de Lima confirmou o depoimento da sua colega de farda. Esclareceu que foram acionados via COPOM em razão de furto cometido dentro da loja. Uma menor de idade havia furtado varios produtos. A menor afirmou que tinha um veículo a esperando do lado de fora. Do lado de fora da loja, encontraram o veículo que a esperava. A menor havia sido pega com os produtos. Dentro do veículo haviam outros produtos sem nota fiscal e idênticos aos produtos que foram encontrados com a menor. No carro tinha um casal e uma criança. Não os conhecia de outras abordagens. As pessoas que estavam no carro negaram os fatos, disseram que só aguardavam a menor. A menor confessou.

Em solo policial os acusados permaneceram silentes (fls. 08/10).

Em juízo, deixaram de comparecer tendo sido decretada a sua revelia.

Essas são as provas e diante delas a ação comporta parcial procedência.

Verifique-se que a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação dos acusados no evento. Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Restou suficientemente demonstrado que a adolescente foi deixada no estabelecimento no veículo peugeot, conduzido por HERBERT, tendo entrado no estabelecimento com uma das comparsas que lhe auxiliou a escolher os bens a serem furtados.

Em seguida, a adolescente passou pelos caixas sem pagar e foi detida quando no estacionamento da loja. Do lado de fora, os demais comparsas, aguardavam a adolescente a fim de empreender fuga do local.

Já a materialidade delitiva restou comprovada, além da prova oral produzida em Juízo, pelo boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão. Adequado ao caso, assim, o desate condenatório em face da prova produzida em Juízo.

A qualificadora referente ao concurso de pessoas restou provada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais e pelo representante legal do estabelecimento. Não há que se falar em afastamento do repouso noturno apenas em razão da posição topográfica do § 1º, do art. 155, do Código Penal. Neste ponto, compulsando recentes julgados dos tribunais superiores, verifica-se a necessidade de novas reflexões sobre a questão topográfica nos tipos penais e seus reflexos na dosimetria da pena.

De fato, não se desconhece que há decisões baseadas na mera argumentação de que, por uma questão topográfica, não caberia aplicar preceito antecedente ao subsequente e que a maior gravidade da figura qualificada e da pena a ela cominada já abrangeria as hipóteses descritas nas majorantes.

Com o tempo, contudo, começou-se a perceber que essa não era a melhor interpretação e que o legislador brasileiro não se ateve a tal critério (o topográfico), quando da elaboração das leis.

Tal entendimento começou, então a mudar notadamente no que diz respeito aos crimes de homicídio e furto, nos quais já se pacificou que a simples posição topográfica dos parágrafos em nada impediria a figura do crime "qualificado- privilegiado", ou mesmo o reconhecimento da figura do "repouso noturno" aos delitos de furtos qualificados.

A doutrina então começou a analisar tais decisões e passou-se a considerar nestes casos que "a posição da causa de aumento no tipo penal, bem como da qualificadora, é completamente indiferente, levando-se em conta o processo trifásico de aplicação da pena. Outras considerações, para não aplicar o aumento do § 1.º às formas qualificadas (§ 4.º ou 5.º), constituem pura política criminal, visando à menor apenação ao acusado, embora distante da técnica de individualização da pena.

Na jurisprudência: STJ: "Entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso noturno é aplicável somente às hipóteses de furto simples, sendo incabível no caso do delito qualificado (Precedente)" (REsp 940.245-RS, 5.ª T., rel. Félix Fischer, 13.12.2007, v.u.); HC 10.240-RS, 6.ª T., rel. Fernando Gonçalves, 21.10.1999, v.u., DJ 14.02.2000, p. 79.

Em seu voto no HC 306.450-SP, a ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou: Destarte, nessa linha de raciocínio, não haveria justificativa plausível para se

aplicar o § 2.º do art. 155 do CP e deixar de impor o § 1.º do referido artigo, que, a propósito, compatibiliza-se com as qualificadoras previstas no § 4.º do dispositivo. Ademais, cumpre salientar que o § 1.º do art. 155 do CP refere-se à causa de aumento, tendo aplicação apenas na terceira fase da dosimetria, o que não revela qualquer prejuízo na realização da dosimetria da pena com arrimo no método trifásico.

Por outro lado, registra-se que não se desconhece o entendimento da Quinta Turma desta Corte segundo o qual somente será cabível aplicação da mencionada causa de aumento, quando o crime for perpetrado na sua forma simples (caput). Todavia, o fato é que, após o entendimento exarado em 2011 no julgamento do EREsp 842.425/RS, no qual se evidenciou a possibilidade de aplicação do privilégio (§ 2.º) no furto qualificado, não há razoabilidade em negar a incidência da causa de aumento (delito cometido durante o repouso noturno) na mesma situação em que presente a forma qualificada do crime de furto.

Em outras palavras, uma vez que não mais se observa a ordem dos parágrafos para a aplicação da causa de diminuição (§ 2.º), também não se considera tal ordem para imposição da causa de aumento (§ 1.º).

Contudo, a causa de aumento deve ser afastada porquanto não há provas de sua configuração. Isso porque, não restou demonstrado que os réus tivessem se valido do horário em que perpetrado o delito por seu período de menor vigilância como, aliás, bem ponderado por ambas as partes.

O furto, doutra parte, foi tentado já a adolescente e seus comparsas não conseguiram subtrair nenhum bem que guarnecia no estabelecimento comercial.

No que diz respeito ao tipo penal do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem prevalecido, outrossim, o entendimento de que trata-se de crime formal, bastando o cometimento do delito em companhia de adolescente, sem necessidade de demonstração que o ato tenha corrompido sua moral, de modo que tenho a tipo penal como por consumado.

Tal entendimento, aliás é o que se faz presente na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova de efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". (Súmula 500)

Caracterizada a infração penal, passo a dosar as penas

1) JENNIFER NATALIA DE SOUSA

Sua Folha de Antecedentes e a Certidão do Distribuidor Criminal foram juntadas aos autos (fls. 57/58 e 73/74).

Do crime de Furto qualificado:

A ré é primária, embora tenha passagens anteriores por ato infracional. Assim não é possível dizer que lhe são desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal e, portanto a pena base será mantida em seu mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase é o caso de se considerar a atenuante da menoridade relativa, artigo 65, inciso I, do Código Penal, porquanto tendo cometido o crime em fevereiro de 2021 a acusada contava com 19 anos de idade. Em que pese a ausência de documento de identidade ou certidão de nascimento, há nos autos documentos oficiais, tais como as certidões de Distribuidor Criminal que dão conta da data de nascimento da acusada. Ocorre que, a pena permanecerá sem alterações porquanto já fixada no mínimo legal, totalizando 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

De outro lado, afasto a agravante do art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal, porquanto não há demonstração nos autos que a epidemia de COVID-19 tenha de qualquer modo contribuído para o cometimento do delito.

Na terceira fase, afastada a ocorrência do furto noturno, verifica-se que o crime foi tentado. Assim, considerando o iter criminis praticado pela ré que foi surpreendido pela polícia dentro do veículo aguardando a adolescente para dar fuga, a pena deve ser diminuída em 2/5, e ser fixada em 1 ano, 2 meses e 12 dias, de

reclusão e 6 dias-multa.

Do crime de Corrupção de menores:

A ré é primária, embora tenha passagens anteriores por ato infracional. Assim não é possível dizer que lhe são desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal e, portanto a pena base será mantida em seu mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase é o caso de se considerar a atenuante da menoridade relativa, porquanto tendo cometido o crime em fevereiro de 2021 a acusada contava com 19 anos de idade. Ocorre que, a pena permanecerá sem alterações porquanto já fixada no mínimo legal, totalizando 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

De outro lado, afasto a agravante do art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal, porquanto não há demonstração nos autos que a epidemia de COVID-19 tenha de qualquer modo contribuído para o cometimento do delito.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas de modo que torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

No mais, os crimes de furto e de corrupção de menores foram praticados em concurso material de crimes, figura prevista no artigo 69 do Código Penal, uma vez que provenientes de desígnios autônomos, devendo as penas serem somadas, perfazendo o total de 02 anos e 02 meses e 12 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Assim, torno essa pena definitiva por inexistência de outras causas a se considerar.

2) HERBERT WENDELL SANTOS RODRIGUES

Sua Folha de Antecedentes e a Certidão do Distribuidor Criminal foram juntadas aos autos (fls. 59/61 e 71).

Do crime de Furto qualificado:

O réu é primário e lhe são inteiramente favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal e, portanto a pena base será mantida em seu mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, afasto a agravante do art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal, porquanto não há demonstração nos autos que a epidemia de COVID-19 tenha de qualquer modo contribuído para o cometimento do delito. De outro lado, não há atenuantes a considerar, de modo que a pena permanece fixada em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, afastada a ocorrência do furto noturno, verifica-se que o crime foi tentado. Assim, considerando o iter criminis praticado pelo réu que foi surpreendido pela polícia dentro do veículo aguardando a adolescente para dar fuga, após tê-la deixado no estacionamento da loja, a pena deve ser diminuída em 2/5, e ser fixada em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão e 6 dias-multa.

Do crime de Corrupção de menores:

O réu é primário e lhe são inteiramente favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal e, portanto a pena base será mantida em seu mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, afasto a agravante do art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal, porquanto não há demonstração nos autos que a epidemia de COVID-19 tenha de qualquer modo contribuído para o cometimento do delito. De outro lado, não há atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena fixada em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas de modo que torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

No mais, os crimes de furto e de corrupção de menores foram praticados em concurso material de crimes, figura prevista no artigo 69 do Código Penal, uma vez que provenientes de desígnios autônomos, devendo as penas serem somadas, perfazendo o

total de 02 anos e 02 meses e 12 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Assim, torno essa pena definitiva por inexistência de outras causas a se considerar

3) BIANCA BARBOSA GASTALDO.

Sua Folha de Antecedentes e a Certidão do Distribuidor Criminal foram juntadas aos autos (fls. 62/64 e 72).

Do crime de Furto Qualificado:

A ré é primária e lhe são inteiramente favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal e, portanto a pena base será mantida em seu mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, afasto a agravante do art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal, porquanto não há demonstração nos autos que a epidemia de COVID-19 tenha de qualquer modo contribuído para o cometimento do delito. De outro lado, não há atenuantes a considerar.

Na terceira fase, afastada a ocorrência do furto noturno, verifica-se que o crime foi tentado. Assim, considerando o iter criminis praticado pela ré que foi surpreendido pela polícia dentro do veículo aguardando a adolescente para dar fuga, a pena deve ser diminuída em 2/5, e ser fixada em 1 ano, 2 meses e 12 dias, de reclusão e 6 dias-multa.

Do crime de Corrupção de menores:

A ré é primária e lhe são inteiramente favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal e, portanto a pena base será mantida em seu mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase não há atenuantes e de outro lado, afasto a agravante do art. 61, inc. II, alínea "j", do Código Penal, porquanto não há demonstração nos autos que a epidemia de COVID-19 tenha de qualquer modo contribuído para o cometimento do delito, permanecendo, portanto, inalterada a pena.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas de modo que torno definitiva a pena de 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

No mais, os crimes de furto e de corrupção de menores foram praticados em concurso material de crimes, figura prevista no artigo 69 do Código Penal, uma vez que provenientes de desígnios autônomos, devendo as penas serem somadas, perfazendo o total de 02 anos e 02 meses e 12 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Assim, torno essa pena definitiva por inexistência de outras causas a se considerar.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva em desfavor de HERBERT WENDELL SANTOS RODRIGUES e BIANCA BARBOSA GASTALDO para os condenar, por incursos nos artigos 155, §4º, inciso IV, cc. Artigo 14, inciso II, do Código Penal, cc artigo 244-B do ECA, cc artigo 69 do Código Penal e JENNIFER NATALIA DE SOUSA, por incurso nos artigos 155, §4º, inciso IV, cc. Artigo 65, inciso I, cc Artigo 14, inciso II, do Código Penal, cc artigo 244-B do ECA, cc artigo 69 do Código Penal, cada qual, à pena de 02 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 16 dias-multa, fixada esta no mínimo legal ante a ausência de comprovação da situação financeira dos condenados.

O montante da pena aplicada e a primariedade dos acusados autorizam a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos exatos termos do que dispõe o art. 44, §2º, do CP, que ficam ora estabelecidas na pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída e Limitação de final de Semana, que deverão ser determinadas no Juízo da Execução. Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, nos termos do disposto no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Tendo em vista a espécie de pena aplicada e ainda o fato de que os réus permaneceram soltos durante toda a instrução, e não havendo motivos suficientes para se decretar sua prisão preventiva, poderão recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.
Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.
Comunique-se a vítima consoante determinação legal.
Elabore-se cálculo da pena de multa aplicada, dando vista as partes.
P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA